

次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。(改)

1. 前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
2. 前科のない甲が窃盗罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、甲に対し、罰金30万円の判決を宣告するに当たり、その執行を猶予することができる。
3. 甲は、判決により、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で起訴され、前記執行猶予期間の経過前に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。(改)
4. 甲は、判決により、拘禁刑1年、2年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で前記執行猶予期間の経過前に起訴され、同執行猶予期間経過後に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対して、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。(改)
5. 拘禁刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合、裁判所は、甲に対して、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。(改)

(参照条文) 刑法 (改)

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

*平成25年法律第49号により、従来から存在する執行猶予を「刑の全部の執行猶予」とし、それに加えて「刑の一部の執行猶予」を創設する、という改正がなされたため、肢1、2、3、4、5で言及される執行猶予は、「刑の全部の執行猶予」を意味することになる。

No211	執行猶予	正答率
H23-12	正解 3	55%

1 正しい

25条1項各号のいずれかにあたり、かつ、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を言い渡す場合に、情状により、1年以上5年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができる（25条1項柱書）。本記述では、甲に前科がないので、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」（25条1項1号）にあたる。そして、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑である（240条前段）ところ、酌量減軽（66条）により、有期拘禁刑の刑の長期及び短期の2分の1を減ずる（71条、68条3号）ので、3年以上10年以下の拘禁刑が処断刑となる。したがって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑3年の判決を言い渡すことができる。よって、拘禁刑3年を言い渡す場合、情状に応じて、25条1項柱書により、5年間、刑の全部の執行を猶予することができる。また、25条1項柱書に基づいて、刑の全部の執行を猶予する場合、保護観察に付するか否かは裁量的であるので（25条の2第1項前段）、保護観察なしにすることも許される。

2 正しい

25条1項による刑の全部の執行猶予は、25条1項各号のいずれかにあたり、かつ、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を言い渡す場合に、情状により、付することができる。本記述では、甲に前科がないので、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」（25条1項1号）にあたる。よって、罰金30万円を言い渡す場合、情状に応じて、25条1項柱書により、刑の全部の執行を猶予することができる。

3 誤っている

甲は前に犯した罪の刑の全部の執行猶予期間中に、窃盗罪を行っており、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」（25条1項1号）にあたらない。また、刑の「執行を終わった日」又は「執行の免除を得た日」から「5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」（25条1項2号）にもあたらない。したがって、25条1項により、刑の全部の執行を猶予することはできない。もっとも、前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある場合、刑の全部の執行を猶予できる（25条2項本文）。しかし、本記述では、言い渡す拘禁刑の期間が3年であるので、25条2項本文により、執行猶予付きの判決を言い渡すことはできない。

4 正しい

刑の全部の執行の猶予を受けた者が、執行猶予を取り消されることなく、猶予期間が経過したときは、刑の言い渡しは効力を失う（27条1項）。そして、刑の言渡し効力を失うことの効果として、25条1項1号の「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」に該当することとなる。本記述では、刑の言い渡しの前に、甲が以前処せられた刑の全部の執行猶予期間が経過しているので、27条により、以前処せられた刑の言渡し効力は失われる。よって、甲は、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」（25条1項1号）にあたり、拘禁刑3年を言い渡す場合、情状に応じて、25条1項1号により、刑の全部の執行を猶予することができる。また、25条1項1号により、刑の執行を猶予する場合、保護観察を裁量的に付すことができるので（25条の2第1項前段）、保護観察付きの判決を下すことができる。

5 正しい

まず、甲は、前に拘禁刑に処せられているので、「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(平成25年改正25条1項1号)にあたらない。また、25条1項2号の「刑に処せられたことがない」とは、確定判決を受けたことがないことをいう。本記述では、前に処せられた刑の執行が終了してから5年が経過する前に、甲に対して、窃盗罪についての判決が言い渡されるので、その判決が確定したときは、甲は、「執行を終わった日」から「5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(25条1項2号)にあたらない。よって、25条1項の要件を満たさない。さらに、甲が前に処せられた刑は、刑の全部の執行を猶予されていないので、25条2項の要件も満たさない。よって、甲に対して刑の全部の執行猶予付きの判決を言い渡すことはできない。